

Resolución 265/2022, de 31 de marzo¹**Número de expediente de la Reclamación:** 57/2022**Administración reclamada:** Institut Català de la Salut**Información reclamada:** Informe de trazabilidad de un historial clínico.**Sentido de la resolución:** Estimación.

Resumen: A la vista de la Reclamación, el ICS considera que la solicitud de la cual deriva la Reclamación propiamente no es una solicitud de información pública, sino un procedimiento de acceso, revisión y cancelación de datos propios (ARCO), regulado por el artículo 15 y siguientes del Reglamento europeo 2016/679, de protección de datos personales, en relación con el cual la garantía del acceso no sería una competencia de la GAIP, sino de la autoridad de protección de datos (que en relación con las Administraciones de Cataluña es el APDCAT). Es cierto que la garantía de acceso a datos personales solicitados por su propio titular está regulado por la legislación de protección de datos personales, más que por la de transparencia y acceso a la información pública, pero este hecho no comporta necesariamente que la GAIP no sea competente, a los efectos de esta garantía (lo que establece el artículo 24.3 LTAIPBG es que “Las solicitudes de acceso a la información pública que se refieran solamente a datos personales del solicitante deben resolverse de acuerdo con la regulación del derecho de acceso establecido por la legislación de protección de datos de carácter personal.”, pero no excluye la competencia de la GAIP para revisar estas resoluciones); sin embargo, la GAIP viene remitiendo al APDCAT la revisión de las solicitudes que sólo piden datos propios de la persona solicitante, pero, de acuerdo con los criterios del APDCAT, se considera competente en los procedimientos de revisión en los que, además de datos propios, la persona reclamante pide también otros datos al poder de la Administración, como es el caso de la identidad de las personas que han consultado la historia clínica de la persona reclamante custodiada por el ICS. Este criterio está sobradamente y sólidamente argumentado por el informe aportado por el APDCAT en este procedimiento. De acuerdo con la ponderación hecha detalladamente por el informe del APDCAT aportado a este procedimiento (antecedente 10), que esta Resolución asume plenamente, merece una mayor protección el derecho de la persona reclamante a conocer la identidad de las personas que han accedido a su historia clínica, y así poder conocer si se han producido accesos inadecuados o improcedentes a sus datos de salud, que son especialmente protegidos por la LTAIPBG y por la legislación de datos personales, que el derecho de las personas que han accedido a la historia clínica de la persona reclamante a proteger su identidad, ya que en este caso el perjuicio que puede causarles el acceso solicitado se proyecta únicamente en el seguimiento de su actividad profesional. Esta consulta no se ha podido llevar a cabo por la falta manifiesta de colaboración del ICS, que a pesar de los reiterados requerimientos de la GAIP se niega a facilitarles los datos de contacto de las terceras personas afectadas a fin de que la Comisión pueda someterles a consulta la Reclamación (trámite especialmente imprescindible si se tiene en cuenta que no lo ha llevado a cabo la ICS con motivo de la tramitación de la solicitud de la cual deriva la Reclamación). En consecuencia, la Resolución es aprobada sin perjuicio de lo que resulte de la consulta a las terceras personas afectadas, que tiene que ser llevada a cabo por el ICS en la fase de ejecución de la Resolución, con el bien entendido que se tendrán que comunicar a la GAIP las eventuales

¹ El texto original de esta resolución, redactado por el ponente, se ha escrito en catalán.

alegaciones que formulen las personas afectadas, que tendrá que valorarlas y determinar hasta qué punto pueden incidir en el sentido y efectos de la Resolución.

Palabras clave: Organismos de la Generalitat. Persona interesada. Historial clínico. Trazabilidad del acceso. ARCO. Reclamación contra falta de entrega. Competencia de la GAIP. Objeto del procedimiento de reclamación. Deber de colaboración en el traslado. Terceras personas afectadas. Datos personales. Acceso a los propios datos. Consulta a las terceras personas afectadas.

Ponente: Josep Mir Bagó.

Antecedentes

1. El 14 de enero de 2022 entra en la GAIP la Reclamación 57/2022, presentada contra el Institut Català de la Salut (ICS), en relación con la solicitud indicada al antecedente siguiente. La persona reclamante solicita el procedimiento de mediación previsto al artículo 42 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) y regulado por los artículos 36 a 41 del Reglamento de la GAIP, aprobado por el Decreto 111/2017, de 18 de julio (RGAIP).
2. La persona reclamante invoca el artículo 15 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos personales, y pide al ICS, a través de la Oficina Virtual de Trámites, sus datos de carácter personal incluidos a su historia clínica y tener información sobre el origen de los datos, cesionarios, usos y finalidades para las cuales se almacenaron, desde el 1 de junio de 2020 hasta la actualidad.
3. El 23 de diciembre de 2021 el Servicio Catalán de la Salud contesta a la persona reclamante indicando que la trazabilidad de su historial médico lo puede consultar a la aplicación Mi Salud.
4. La Reclamación presentada el 14 de enero de 2022 indica que no se le ha facilitado la información solicitada y hace las consideraciones siguientes: “En mayo del 2021 pedí informe de trazabilidad de mi historial clínico a mi CAP de referencia (CAP Sagrada Familia de Manresa). Hasta la fecha de hoy no he recibido respuesta, he hecho una queja en la página del CatSalut y me han respondido al mes y medio que esta información la puedo encontrar a la aplicación de mi salud. Esta función de la aplicación hace meses que no funciona y si se diera el caso de que sí, no te da la información que necesito porque quiero saber a las personas que han consultado mi historia clínica en los últimos dos años. El motivo es que tengo sospechas fundadas de qué han habido irregularidades de tratamiento de mi historia en este sentido”.
5. El 25 de enero de 2022 la GAIP comunica la Reclamación al ICS y le requiere que, dentro del plazo de quince días establecido por el artículo 33.4 RGAIP, le envíe un informe sobre ella,

así como también copia del expediente de la solicitud de información de la que deriva y, en general, de los antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la Reclamación.

6. El 25 de enero de 2022 la GAIP admite provisionalmente la Reclamación, informa a la persona reclamante sobre los aspectos más relevantes de su tramitación y de la posición jurídica que ostenta como persona interesada, de conformidad con la legislación de procedimiento administrativo y la de transparencia y acceso a la información pública. Le pide especialmente que informe a la GAIP inmediatamente de las comunicaciones que reciba de la Administración reclamada relativas a la información pública solicitada.
7. El 9 de febrero de 2022 la persona reclamante comunica a la GAIP la renuncia al procedimiento de mediación.
8. El 15 de febrero de 2022 la GAIP pide a la Autoridad Catalana de Protección de Datos Personales (APDCAT) el informe previsto por el artículo 42.8 LTAIPBG y comunica en las partes la ampliación del plazo para resolver causada por esta actuación.
9. El 1 de marzo de 2022 la GAIP recibe el informe del ICS, que defiende la inadmisibilidad de la Reclamación porque considera que tiene por objeto un procedimiento de acceso a datos propios (ARCO), de la competencia del APDCAT; también argumenta que la solicitud no puede ser estimada: “el origen de esta reclamación es una solicitud de derechos ARCO, en concreto una solicitud del ejercicio del derecho de acceso (trazabilidad) efectuada por el señor xxxx y no una solicitud de información pública dirigida a la Dirección Gerencia del Institut Català de la Salut. La Autoridad Catalana de Protección de Datos es quien tiene la competencia para resolver este procedimiento, de acuerdo con lo que establecen los artículos 5.b) y 8.2.b) de la Ley 32/2010, del 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (en adelante Ley 32/2010) La Agencia Catalana de Protección de Datos, autoridad independiente creada por la Ley 5/2002, del 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos, es quien vela por la garantía del derecho a la protección de datos en el ámbito de las administraciones públicas de Cataluña mediante el asesoramiento, la difusión del derecho y el cumplimiento de las funciones de control establecidas por el ordenamiento jurídico. (...) Por lo tanto, la persona reclamante lo que tendría que haber hecho es interponer una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos en los plazos exigibles de acuerdo con la normativa mencionada, y no ante la GAIP ya que este órgano administrativo no tiene atribuidas las competencias para resolver reclamaciones contra solicitudes de derechos ARCO, comprendidas en un procedimiento de tutela de derechos. Lo que no puede hacer el reclamante es interponer una Reclamación en la GAIP, utilizando una vía impropia, sin previamente haber efectuado una solicitud de información pública. Más si tenemos en cuenta que la GAIP no tiene atribuidas las competencias legales para resolver un procedimiento especial de tutela de derechos, en tanto que no tiene legalmente

encomendadas las competencias para resolver este tipo de reclamaciones, ya que estos procedimientos especiales tienen establecido otro régimen de acceso especial que se encuentra regulado en la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. De la misma manera que la Agencia Catalana de Protección de Datos no es el órgano competente para resolver reclamaciones contra solicitudes de información pública, en este caso, la GAIP tampoco es el órgano competente para resolver reclamaciones de procedimientos especiales de tutela de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales. (...) Ahora bien, en el caso que la GAIP acuerde resolver sobre esta Reclamación 57/2022, esta también tiene que ser desestimada por las siguientes razones: La Ley estatal básica 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente, establece en su artículo 18 el derecho de acceso a la historia clínica en los términos siguientes: "Derechos de acceso a la historia clínica: 1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas que señala el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran. Los centros sanitarios tienen que regular el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos. 2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica también se puede ejercer por representación debidamente acreditada." 3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no se puede ejercer en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan recogidas en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales que participan en su elaboración, que pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. Por su parte, el artículo 13 de la Ley catalana 21/2000, de 29 de diciembre, de Autonomía del Paciente y Derechos de Información y Documentación Clínica, determina lo siguiente: "Derechos de acceso a la historia clínica 1. Con las reservas señaladas en el apartado 2 de este artículo, el paciente tiene derecho a acceder a la documentación de la historia clínica descrita por el artículo 10, y a obtener una copia de los datos que figuran. Corresponde en los centros sanitarios regular el procedimiento para garantizar el acceso a la historia clínica. 2. El derecho de acceso del paciente a la documentación de la historia clínica nunca puede ser en perjuicio del derecho de terceros a la confidencialidad de los datos de estos que figuran en la mencionada documentación, ni del derecho de los profesionales que han intervenido en la elaboración de esta, que pueden invocar la reserva de sus observaciones, apreciaciones o anotaciones subjetivas. Respecto de la identidad de las personas profesionales del ICS que habrían accedido a su historia clínica, hay que precisar que esta información no forma parte del derecho de acceso regulado por el artículo 15 de la LOPD. Por el contrario, sí forma parte del derecho de acceso la información relativa a las comunicaciones de datos de la HC, es decir los eventuales accesos efectuados por personas y/o entidades ajenas al ICS. El criterio expresado en el párrafo anterior en el sentido de considerar que la información sobre la

identidad de los autores de los accesos cuando se trata de personal adscrito al responsable del fichero o tratamiento no forma parte del derecho de acceso al no tener la consideración de comunicaciones de datos, y por lo tanto no se tiene que informar sobre tal identidad con motivo de una solicitud de acceso en términos LOPD, ha sido mantenido por la Autoridad Catalana de Protección de Datos en varias resoluciones. Es criterio consolidado de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, recogido en varias resoluciones y dictámenes (por todos, PT 60/20, citada al escrito de alegaciones del ICS, PT 21/2019 y 60/2020 y CNS 8/2019, así como la PT 118/2021, la cual corresponde a la Reclamación de la GAIP 44/2022, que no forma parte del derecho de acceso previsto en el artículo 15 del RGPD conocer la identificación del personal del responsable del tratamiento (en este caso, el ICS) que ha accedido a la historia clínica. Y eso porque, en esencia, este tipo de acceso no se puede considerar una comunicación de datos a terceros destinatarios; y, consiguientemente, no se puede meter en el apartado 15.1.c) del RGPD. Asimismo, este criterio también ha sido confirmado por la jurisprudencia en varias sentencias, entre otros, la dictada por la Audiencia Nacional el 26/02/2014: “debe destacarse que solicitud de acceso a información formulada por la aquí demandante ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es ajena al contenido del derecho de acceso a datos personales que reconoce al titular de tales datos el artículo 15 de la LOPD, pues va dirigida a obtener información sobre la identidad de los funcionarios o servidores públicos que pudieran hubieran accedido a los datos personales de la actora, presumiendo que pudieran haberlos cedido a terceros. Por consiguiente, no tiene por objeto la obtención de información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, del origen de tales datos y de las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos por el responsable de fichero, sino acerca de los datos de identidad de aquellos empleados públicos pertenecientes a la organización administrativa del responsable del fichero que hubieran accedido a los mismos, que no quedan comprendidos en el derecho de acceso reconocido al titular de datos personales y configurado legalmente en los términos expresados”. En consecuencia, para dar cumplimiento al art. 15 de la LOPD, hay que informar sobre las comunicaciones que eventualmente se hubieran efectuado en terceros. O en caso de que no se hubiera efectuado ninguna comunicación, informar en este sentido, sin que sea exigible sin embargo, desde el punto de vista del derecho de acceso, informar sobre los eventuales accesos llevados a cabo por usuarios concretos del propio responsable (ICS). Por último, el artículo 18 de la LOPD, en lo referente a la tutela de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, establece en sus apartados 1 y 2 el siguiente: “1. Las actuaciones contrarias a lo que dispone esta Ley pueden ser objeto de reclamación para los interesados ante la Agencia de Protección de Datos, en la forma que se determine por reglamento. 2. El interesado en el cual se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, lo puede poner en conocimiento

de la Agencia de Protección de Datos o, si ocurre, del organismo competente de cada comunidad autónoma, que se tiene que asegurar de la procedencia o improcedencia de la denegación.” Conclusiones: Por los motivos supra expuestos, procede que la GAIP inadmita la reclamación efectuada por el señor xxxx porque esta se ha dirigido a un órgano administrativo que no tiene la competencia funcional para resolverla. Subsidiariamente esta Reclamación tiene que ser desestimada, porque la pretensión de conseguir la identidad de los profesionales del ICS que hayan accedido a su historia clínica no forma parte del derecho de acceso, al no tener la consideración de comunicación de datos, y por lo tanto el ICS no tiene el deber legal de informar sobre tal identidad con motivo de una solicitud de acceso en términos establecidos en la LOPD”.

10. El 3 de marzo de 2022 la GAIP recibe el informe del APDCAT, que concluye: “La normativa de protección de datos no impide comunicar a la persona reclamante la información que solicita, relativa a la trazabilidad de los accesos a su historia clínica, en concreto, conocer la identidad de las personas que han consultado su historia clínica durante el periodo de dos años solicitado”. Estas conclusiones se fundamentan en las consideraciones siguientes: “La reclamación se refiere a información de la historia clínica del propio reclamante. En concreto, el reclamante pide conocer la información relativa a “las personas que han consultado mi historia clínica en los últimos dos años.” La historia clínica recopilación el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial de cada enfermo, identificando los médicos y el resto de profesionales asistenciales que ha intervenido (art. 9.1 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica (en adelante, Ley 21/2000). La historia clínica del paciente contiene la información relativa a esta asistencia, y que detalla el artículo 10.1 de la Ley 21/2000. Como ha recordado esta Autoridad (entre otros, en los Dictámenes CNS 8/2019, CNS 53/2019, o CNS 48/2021), la persona reclamante, de entrada, tiene derecho de acceso respecto de su propia información personal, en los términos que prevé el artículo 15.1 RGPD. A los efectos que interesan, y dado que el reclamante pide conocer a las personas que habrían accedido a su historia clínica, el RGPD reconoce el derecho de la persona afectada o interesada a solicitar y a obtener del responsable del tratamiento una copia de sus datos personales sometidos a tratamiento, incluida determinada información sobre este tratamiento, como, a los efectos que interesan, los destinatarios a quien se haya comunicado o se prevea comunicar estos datos (art. 15.1.c) RGPD). Ahora bien, como ha recordado esta Autoridad, no pueden considerarse como “comunicación”, los accesos del personal que presta servicios para el propio responsable (art. 4.7 RGPD), el ICS en el caso que nos ocupa, dado que este personal forma parte del propio responsable. Así, los accesos hechos por el propio personal asistencial u otros perfiles (por ejemplo, personal administrativo) del ICS no se pueden considerar como una información que forme parte del derecho de acceso previsto a la

normativa de protección de datos (art. 15.1.c) RGPD). Por la vía del ejercicio del derecho de acceso a los datos personales previsto a la normativa de protección de datos (art. 15 RGPD), el reclamante puede acceder a la identidad de los destinatarios de la información que no sean personal del ICS o de algún encargado del tratamiento de este. En cambio, no podría acceder a otra información incluida en la solicitud con respecto a los accesos de personas que están bajo la dependencia del responsable. Habrá que ver si de acuerdo con la legislación de transparencia puede tener acceso a esta información. (...) La información solicitada, en lo referente a la trazabilidad de los accesos a la historia clínica del reclamante, formaría parte del registro o control de accesos a las historias clínicas, de que dispone el responsable. Se trata de información pública a los efectos del LTC y quedaría, por lo tanto, sometida al régimen de acceso previsto en esta normativa, que establece, como criterio general, que el derecho de acceso a la información pública sólo puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes (artículo 20 y siguientes). En este sentido, y tratándose de información que comprende datos personales, hay que aplicar las previsiones de los artículos 23 y 24 del LTC. (...) El reclamante explicita el motivo de su solicitud, en la reclamación dirigida a la GAIP, en los siguientes términos: "(...). El motivo es que tengo sospechas fundadas de haber habido irregularidades de tratamiento de mi historia en este sentido." Así, claro está que la finalidad pretendida responde en este caso a la voluntad del propio titular de la historia clínica de comprobar posibles accesos indebidos por, si fuera el caso, constatar irregularidades de las que tiene sospechas. Eso le tendría que permitir, si procede, ejercer alguna acción o reclamación relacionada con este acceso indebido o con las consecuencias que eso haya podido tener para sus intereses y derechos como paciente. A efectos de ponderación, hay que tener presente que la historia clínica responde a varios usos, siendo el principal la prestación de una asistencia adecuada al paciente. (...) Así, de entrada, cualquier paciente puede tener un interés legítimo a conocer qué accesos se han producido a su historia clínica como mecanismo para la efectividad de los derechos que la legislación sanitaria le reconoce. Este derecho de información del paciente se configura en términos bastante amplios (artículo 2 Ley 21/2000 y art. 4 Ley 41/2002), al establecer que este tiene que poder disponer de toda la información referida a los diferentes aspectos que repercuten en su tratamiento y por lo tanto en su salud (...) Este derecho de información amplio englobaría, entre otros, conocer a qué profesionales están a cargo y han intervenido en el proceso asistencial, es decir, conocer a qué profesionales atienden a un paciente y, por extensión, se puede considerar que incluiría conocer a qué profesionales han accedido a la historia clínica para llevar a cabo o participar en esta atención, o para realizar las funciones previstas en la legislación de autonomía del paciente (funciones administrativas, acceso para los servicios de inspección de la calidad de la asistencia, etc.). La propia legislación reguladora de la historia clínica y de los derechos del paciente, limitan los términos en que

determinados profesionales pueden acceder a las historias clínicas de los pacientes. Por lo tanto, dado que la historia clínica es el instrumento principal para tomar decisiones sobre la asistencia que recibe al paciente, es innegable que comprobar si se han producido accesos indebidos, formaría parte del interés legítimo que, como a titular de la historia clínica tiene el propio paciente. Además, recordamos que la legislación en materia de protección de datos impone al responsable del tratamiento la obligación de adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales tratados, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito (art. 5 y 24 RGPD). Específicamente en el ámbito que nos ocupa, el artículo 9.4 de la Ley 21/2000 dispone el siguiente: “4. Los centros sanitarios tienen que adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales recogidos y evitar la destrucción o la pérdida accidental, y también el acceso, la alteración, la comunicación o cualquier otro procesamiento que no sean autorizados.” Al mismo tiempo, la normativa de protección de datos reconoce al afectado el derecho a presentar una reclamación delante, en este caso, esta Autoridad cuando considere que se ha producido un incumplimiento o infracción de la normativa de protección de datos que afecta al tratamiento de sus datos personales (art. 77 RGPD), como sería el caso de haberse producido un acceso indebido a los datos de su historia clínica laboral. Eso, sin perjuicio de poder emprender otras acciones legales que considere oportunas. En este contexto, parece claro que, con el fin de emprender esta u otras acciones legales para la defensa de sus derechos e intereses, el reclamante tiene que poder acceder a determinada información sobre los accesos a su historia clínica. En concreto, el reclamante tiene que poder conocer qué profesionales han accedido a su información, con el fin de poder corroborar o no las sospechas de accesos indebidos, y constatar una posible irregularidad con respecto a las medidas que la normativa exige al responsable en relación con la gestión de la historia clínica del reclamante. (...) En el caso que nos ocupa esta habilitación estaría fundamentada en el interés legítimo que con carácter general hace falta reconocer al paciente atendido -el reclamante-, que resulta un elemento de ponderación que justificaría, en los términos apuntados, desde la perspectiva de la normativa de protección de datos, el acceso al registro de accesos producidos a la propia historia clínica, para poder contrastar si estos accesos se ajustan a las previsiones de la legislación estudiada y comprobar las sospechas de irregularidades que el reclamante explicita. Por otra parte, a los efectos de la ponderación necesaria, hay que analizar la posible afectación que el acceso a la información pública solicitada podría comportar por los derechos de las personas afectadas (los profesionales del ICS que hayan accedido a la historia clínica del reclamante, cuyos datos puedan constar en el registro de accesos a efectos de trazabilidad). Los datos de estos profesionales son datos personales protegidos por los principios y garantías de la normativa de protección de datos. Los datos de los profesionales que acceden a la historia clínica de un paciente pueden ser no

sólo datos identificativos o laborales (identidad, cargo, categoría o perfil profesional), sino también información relativa al propio acceso (fecha del acceso y centro desde donde se ha producido). Los trabajadores (en este caso, profesionales asistenciales, o de otros perfiles, de los servicios de salud), pueden hacer un cierto uso privado de los recursos informáticos o las herramientas de trabajo, como un teléfono móvil, un ordenador, etc., que la empresa pone a disposición de estos para el desarrollo de las tareas y funciones que tienen encomendadas, de acuerdo con las políticas de uso que haya establecido cada empresa. Respecto de este uso privado, en términos generales, los trabajadores pueden tener cierta expectativa de privacidad. Ahora bien, más allá de eso, no parece que un trabajador pueda tener las mismas expectativas cuándo utiliza estas mismas herramientas para acceder a información de uno tercero (el paciente), a la cual sólo tendría que acceder para cumplir determinadas tareas que tiene asignadas en relación con la prestación de asistencia sanitaria al paciente, en este caso. (...) Hace falta tener en cuenta que, según la legislación de autonomía del paciente, cualquier acceso a las historias clínicas tiene que ser necesariamente gestionado, protocolizado y supervisado por el responsable (art. 11 Ley 21/2000). La trazabilidad de los accesos a las historias clínicas resulta una medida necesaria para asegurar la protección de la información que se contiene. Por lo tanto, no parece que la expectativa de privacidad que los trabajadores afectados podrían tener en otras parcelas de su actividad profesional, resulte aplicable en igual medida cuando estos trabajadores acceden y gestionan información de otros (no sólo del propio paciente, sino también datos de otras personas, como familiares del paciente o de otros profesionales que lo atienden). En definitiva, si tenemos en cuenta que los trabajadores que puedan estar afectados para la reclamación presentada tienen que tener información previa sobre el uso correcto de las historias clínicas y sobre la trazabilidad de los accesos que se producen, no parece que la expectativa de privacidad de estos trabajadores, cuando acceden y gestionan información de otros (expectativas que sí pueden tener en otras parcelas de su actividad profesional), pueda suponer un contrapeso determinante en la ponderación mencionada. Por lo tanto, el derecho a la protección de datos de las personas que hayan accedido no justificaría la denegación del acceso por parte del reclamante en el registro de accesos a su propia historia clínica, en concreto, conocer la identidad de los profesionales que han accedido. En cualquier caso, recordamos que el principio de minimización de datos (artículo 5.1.c) RGPD), exige que el acceso se limite a los datos estrictamente necesarios para alcanzar la finalidad pretendida. Conocer la identidad y, si procede, el cargo, categoría o perfil de los profesionales que acceden a la historia clínica y otros datos vinculados al acceso (fecha y hora, lugar, motivo etc.), resultaría proporcionado, ya que permite dar cumplimiento a la finalidad explicitada por el reclamante de conocer “a las personas que han consultado mi historia clínica” y comprobar, si procede, accesos indebidos de los que tiene sospecha. En cambio, no resultaría pertinente comunicar otros datos personales, como el número de DNI,

datos de contacto de estos profesionales u otros que, vale a decir, el reclamante tampoco pide. Finalmente hay que recordar que, según dispone el artículo 31 del LTC, si la solicitud de información pública puede afectar derechos o intereses de terceros, identificados o fácilmente identificables, se les tiene que dar traslado de la solicitud, a fin de que puedan hacer las alegaciones que consideren convenientes, en aquellos casos en que puedan ser determinantes del sentido de la resolución. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa habrá que otorgar el trámite de audiencia a las personas afectadas en relación con el registro de accesos a la historia clínica del reclamante, a fin de que puedan hacer alegaciones y se pueda valorar, si procede, la concurrencia de alguna circunstancia adicional que se tenga que tener en cuenta a los efectos de la ponderación”.

11. El 7 de marzo de 2022 la GAIP comunica en las partes el informe del APDCAT, para su conocimiento.
12. El 7 de marzo de 2022 la GAIP recuerda al ICS que le ha requerido la identidad de las personas afectadas para la Reclamación, de las cuales pide también los datos de contacto para hacerles traslado de la Reclamación, en aplicación de los artículos 31 LTAIPBG y 34 RGAIP. No consta respuesta del ICS a este requerimiento.

Fundamentos jurídicos

1. Competencia de la GAIP y contenido y alcance generales del derecho de acceso a la información pública

El artículo 39.1 LTAIPBG establece que “Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, encargada de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública que regula el presente título.”. El artículo 29 RGAIP desarrolla este precepto y concreta que también pueden ser objeto de reclamación delante de la GAIP las comunicaciones que sustituyan las resoluciones y el incumplimiento material del derecho de acceso, cuando este ha sido reconocido expresa o presuntamente.

A la vista de la Reclamación, el ICS considera que la solicitud de la cual deriva la Reclamación propiamente no es una solicitud de información pública, sino un procedimiento de acceso, revisión y cancelación de datos propios (ARCO), regulado por el artículo 15 y siguientes del Reglamento europeo 2016/679, de protección de datos personales, en relación con el cual la garantía del acceso no sería una competencia de la GAIP, sino de la autoridad de protección de datos (que en relación con las Administraciones de Cataluña es el APDCAT). Es cierto que la garantía de acceso

a datos personales solicitados por su propio titular es regulada por la legislación de protección de datos personales, más que por la de transparencia y acceso a la información pública, pero este hecho no comporta necesariamente que la GAIP no sea competente, a los efectos de esta garantía (lo que establece el artículo 24.3 LTAIPBG es que “Las solicitudes de acceso a la información pública que se refieran solamente a datos personales del solicitante deben resolverse de acuerdo con la regulación del derecho de acceso establecido por la legislación de protección de datos de carácter personal.”, pero no excluye la competencia de la GAIP para revisar estas resoluciones); sin embargo, la GAIP viene remitiendo al APDCAT la revisión de las solicitudes que sólo piden datos propios de la persona solicitando, pero, de acuerdo con los criterios del APDCAT, se considera competente en los procedimientos de revisión en los que, además de datos propios, la persona reclamante pide también otros datos en poder de la Administración, como es el caso de la identidad de las personas que han consultado la historia clínica de la persona reclamante custodiada por el ICS. Este criterio es sobradamente y sólidamente argumentado por el informe aportado por el APDCAT a este procedimiento: “como ha recordado esta Autoridad, no pueden considerarse como “comunicación”, los accesos del personal que presta servicios para el propio responsable (art. 4.7 RGPD), el ICS en el caso que nos ocupa, dado que este personal forma parte del propio responsable. Así, los accesos hechos por el propio personal asistencial u otros perfiles (por ejemplo, personal administrativo) del ICS no se pueden considerar como una información que forme parte del derecho de acceso previsto a la normativa de protección de datos (art. 15.1.c) RGPD). Por la vía del ejercicio del derecho de acceso a los datos personales previsto a la normativa de protección de datos (art. 15 RGPD), el reclamante puede acceder a la identidad de los destinatarios de la información que no sean personal del ICS o de algún encargado del tratamiento de este. En cambio, no podría acceder a otra información incluida en la solicitud con respecto a los accesos de personas que están bajo la dependencia del responsable” (antecedente 10).

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la GAIP es competente para tramitar y resolver esta Reclamación.

El artículo 2.c LTAIPBG define el derecho de acceso a la información pública como “el derecho subjetivo que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la información pública, en los términos y las condiciones regulados por esta ley”. Por su parte, el apartado b del mismo precepto define la información pública como “la información elaborada por la Administración y la que esta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los otros sujetos obligados de acuerdo con lo que establece esta ley”.

Según el artículo 18.1 LTAIPBG, “Las personas tienen el derecho de acceder a la información pública, a qué hace referencia el artículo 2.b, a título individual o en nombre y representación de cualquier persona jurídica legalmente constituida”. Y el artículo 20.1 de la misma ley añade que “El

derecho de acceso a la información pública se garantiza a todas las personas, de acuerdo con lo que establece esta ley. El derecho de acceso a la información pública sólo puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes”.

Asimismo, los apartados 2 y 3 del artículo 20 LTAIPBG establecen los siguientes requisitos y criterios para la aplicación de los límites legales al derecho de acceso a la información pública: “2. Las limitaciones legales al derecho de acceso a la información pública tienen que ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, se tienen que interpretar siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no se pueden ampliar por analogía. 3. Para aplicar límites al derecho de acceso a la información pública, la Administración no dispone de potestad discrecional y tiene que indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivación hace falta explicitar el límite que se aplica y razonar debidamente las causas que fundamentan la aplicación”.

Además, los límites legales al derecho de acceso a la información pública no son de aplicación automática y absoluta (el encabezamiento del artículo 21 LTAIPBG se refiere expresamente en que los límites enumerados por este precepto “pueden” llevar a la denegación del acceso solicitado), de manera que el artículo 22 de la misma Ley requiere que sean aplicados de acuerdo con criterios de proporcionalidad y temporalidad: “Los límites aplicados al derecho de acceso a la información pública tienen que ser proporcionales en el objeto y la finalidad de protección. La aplicación de estos límites tiene que atender las circunstancias de cada caso concreto, especialmente la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso a la información. 2. Los límites del derecho de acceso a la información pública son temporales si así lo establece la ley que los regula, y se mantienen mientras perduran las razones que justifican la aplicación”.

2. *Sobre el derecho de la persona reclamante a la información solicitada*

La información solicitada son los datos de carácter personal que hay a la historia clínica de la persona reclamante, incluida la información sobre el origen de los datos, cesionarios, usos y finalidades para las cuales se almacenaron, desde el 1 de junio de 2020 hasta la actualidad. La Reclamación formulada insiste en que la persona reclamante quiere conocer las personas que han consultado su historia clínica en los últimos dos años porque tiene sospechas fundadas de irregularidades de tratamiento de su historia clínica, y pone de manifiesto que el recurso al cual se ha remitido su solicitud (la aplicación “mi salud”) no le proporciona esta información.

En la medida en que la historia clínica solicitada está al poder de un organismo público sujeto al LTAIPBG, como es el caso del ICS, es información pública, vista la definición que hace de este término el artículo 2.b LTAIPBG. En consecuencia, y en aplicación de los artículos 18.1 y 20.1

LTAIPBG, cualquier persona tiene derecho a acceder, a menos que concurran límites que puedan determinar la denegación.

Los límites que contribuyen a la información solicitada son los relativos a la protección de datos personales. Por una parte, los datos personales de la misma persona reclamante, relativas a su salud y que, por lo tanto, tienen la condición de datos personales especialmente protegidas por el artículo 23 LTAIPBG, según el cual Las solicitudes de acceso a la información pública deben ser denegadas si la información que se desea obtener contiene datos personales especialmente protegidos, como los relativos a la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial, la salud y la vida sexual, así como los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, salvo que el afectado lo consienta expresamente mediante un escrito que debe acompañar la solicitud.". No obstante, dado que quien pide la información de la historia clínica es la misma persona que es titular, el límite del artículo 23 LTAIPBG no le es aplicable.

Por otra parte, también son afectados por la solicitud los datos personales de las personas que han entrado a o consultado la historia clínica de la persona reclamante los últimos dos años, ya que la persona reclamante pide concretamente la identidad. El acceso solicitado a estos datos se tiene que regir por el artículo 24.2 LTAIPBG, según el cual "Si se trata de otra información que contiene datos personales no incluidos en el artículo 23, se puede dar acceso a la información, previa ponderación razonada del interés público en la divulgación y los derechos de las personas afectadas. Para realizar dicha ponderación deben tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: a) El tiempo transcurrido. b) La finalidad del acceso, especialmente si tiene una finalidad histórica, estadística o científica, y las garantías que se ofrezcan. c) El hecho de que se trate de datos relativos a menores de edad. d) El hecho de que pueda afectar a la seguridad de las personas.". Este precepto, pues, autoriza el acceso a los datos de la identidad de las personas que han accedido a la historia clínica de la persona reclamante, previa ponderación de los intereses en juego." De acuerdo con la ponderación hecha detalladamente por el informe del APDCAT aportado a este procedimiento (antecedente 10), que esta Resolución asume plenamente, merece una mayor protección el derecho de la persona reclamante a conocer la identidad de las personas que han accedido a su historia clínica, y así poder conocer si se han producido accesos inadecuados o improcedentes a sus datos de salud, que son especialmente protegidos por la LTAIPBG y por la legislación de datos personales, que el derecho de las personas que han accedido a la historia clínica de la persona reclamante a proteger su identidad, ya que en este caso el perjuicio que puede causarles el acceso solicitado se proyecta únicamente al seguimiento de su actividad profesional.

En aplicación de las anteriores consideraciones, es procedente declarar el derecho de la persona reclamante a la información solicitada, sin perjuicio de la necesidad de consultar previamente a las terceras personas afectadas.

3. Consulta a las terceras personas afectadas

Según el artículo 31.1 LTAIPBG, "Si la solicitud de información pública puede afectar a derechos o intereses de terceros, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, en caso de que los posibles afectados estén identificados o sean fácilmente identificables se les debe dar traslado de la solicitud, y tienen un plazo de diez días para presentar alegaciones si estas pueden resultar determinantes del sentido de la resolución.". Como ya se ha apuntado al fundamento jurídico anterior, está claro que en este caso la solicitud puede afectar a los derechos (concretamente: el derecho de protección de sus datos personales, sin perjuicio de otros que puedan concurrir) de las personas que han accedido a la historia clínica de la persona reclamante y, por lo tanto, el acceso solicitado les debe ser sometido previamente a consulta. Eso no quiere decir que puedan impedirlo con su mera voluntad, pero sí que tienen derecho a exponer eventuales circunstancias en las que el acceso solicitado pueda causarles, si procede, perjuicios de especial intensidad, que eventualmente podrían llegar a decantar en sentido contrario la ponderación hecha en el fundamento jurídico anterior, y también tienen derecho a oponerse al acceso solicitado, caso en el cual el acceso en cuestión no se podría producir hasta haber transcurrido el plazo para impugnar la resolución de la Reclamación en vía contenciosa administrativa (artículo 34.3 LTAIPBG).

El caso es, sin embargo, que esta consulta no se ha podido llevar a cabo por la falta manifiesta de colaboración del ICS, que a pesar de los reiterados requerimientos de la GAIP se niega a facilitarles los datos de contacto de las terceras personas afectadas a fin de que la Comisión pueda someterlas a consulta la Reclamación (trámite especialmente imprescindible si se tiene en cuenta que no lo ha llevado a cabo la ICS con motivo de la tramitación de la solicitud de la cual deriva la Reclamación).

En consecuencia, la Resolución es aprobada sin perjuicio de lo que resulte de la consulta a las terceras personas afectadas, que tiene que ser llevada a cabo por el ICS en la fase de ejecución de la Resolución, con el bien entendido que se tendrán que comunicar a la GAIP las eventuales alegaciones que formulen las personas afectadas, que tendrá que valorarlas y determinar hasta qué punto pueden incidir en el sentido y efectos de la Resolución.

4. Seguimiento de la ejecución

El artículo 43.5 LTAIPBG establece que "la Administración debe comunicar a la Comisión las actuaciones realizadas para ejecutar los acuerdos de mediación y para dar cumplimiento a las

resoluciones dictadas por la Comisión". Sobre la base de estas comunicaciones y de las efectuadas por las personas interesadas, la GAIP debe hacer seguimiento del cumplimiento de sus resoluciones, de acuerdo con lo previsto por los artículos 48 y siguientes RGAIP y por el apartado 30 de su Manual de reclamación, pudiendo adoptar las medidas que allí se prevén en caso de incumplimiento.

El artículo 43 LTAIPBG establece que si la Administración incumple el plazo fijado por los acuerdos de mediación o por las resoluciones de la GAIP para entregar la información reclamada, las personas interesadas lo pueden comunicar a la Comisión para que ésta requiera su cumplimiento; la desatención de este requerimiento, vista la remisión expresa hecha a este precepto por el artículo 77.2.b LTAIPBG, debe calificarse de infracción muy grave en relación con el derecho de acceso a la información pública (que puede ser sancionada de acuerdo con los artículos 81 y 82 LTAIPBG). El artículo 49.2 RGAIP prevé que, a los efectos anteriores, la Comisión puede poner estos hechos en conocimiento de los órganos competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador correspondiente a que hace referencia el artículo 86 LTAIPBG.

Asimismo, el artículo 25.2.k RGAIP prevé la publicación en el web de la Comisión de los casos en los que sus requerimientos han sido desatendidos por los sujetos obligados.

5. Publicidad de las resoluciones de la GAIP

El artículo 44 LTAIPBG prevé que las resoluciones de la GAIP deben publicarse en el portal de la Comisión previsto en el artículo 25 RGAIP, previa disociación de los datos personales.

Resolución

Sobre la base de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Pleno de la GAIP, en la sesión de 31 de marzo de 2022, resuelve por unanimidad:

1. Estimar la Reclamación 57/2022 y declarar el derecho de la persona reclamante a acceder a los datos de carácter personal que hay a su historia clínica, incluida la información sobre el origen de los datos, cesionarios y personas que la han consultado, usos y finalidades para las cuales se almacenaron, desde el 1 de junio de 2020 hasta la fecha de presentación de la solicitud indicada en antecedente 2.
2. Requerir al ICS para que en el plazo de 10 días desde la recepción de esta Resolución, y en aplicación de lo previsto por el artículo 31 LTAIPBG, someta la Reclamación, acompañada del texto de esta Resolución, a las personas que en el periodo indicado en el apartado anterior hayan accedido a la historia clínica de la persona reclamante, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles por formular alegaciones o/y para manifestar su oposición al acceso solicitado. Al

hacer la consulta, el ICS tiene que facilitar a las personas consultadas los datos de contacto de la GAIP e indicarles que tienen que comunicar a la Comisión las alegaciones u otras manifestaciones que quieran formular, a fin que la Comisión pueda valorar si conviene alterar el sentido de la resolución indicado en el párrafo anterior, o confirmarlo.

3. Requerir al ICS para que haga efectivo el derecho declarado en el apartado 1 y facilite a la persona reclamante la información solicitada tan pronto como le requiera la GAIP, una vez finalizado el proceso de consulta indicado en el apartado anterior.
4. Requerir al ICS a informar la GAIP, dentro del plazo de quince días, del órgano o la persona responsable del cumplimiento de esta Resolución, así como de las actuaciones llevadas a cabo para cumplirla.
5. Invitar a la persona reclamante que informe en la GAIP de cualquier incidencia a que se produzca con motivo del cumplimiento de esta Resolución.
6. Declarar finalizado el procedimiento relativo a la Reclamación 57/2022 y disponer la publicación de esta resolución en la web de la GAIP.

Elisabet Samarra Gallego

Presidenta

Los plazos previstos en esta Resolución para la entrega de la información deben contarse en días hábiles (descontando festivos y sábados) a partir del día siguiente de la recepción de su notificación por la Administración reclamada, salvo previsión específica en sentido diferente.

La Administración obligada puede solicitar a la GAIP la ampliación del plazo otorgado para hacer efectiva la entrega de la información. Esta solicitud sólo puede ser tomada en consideración si se comunica a la GAIP antes de que termine el plazo fijado en la Resolución, y debe fundamentarse en circunstancias que no hayan podido ser tenidas en cuenta por la Comisión antes de dictar su Resolución. La GAIP únicamente otorgará la ampliación solicitada si la Administración obligada justifica de forma precisa y consistente su necesidad.

Si la Administración obligada no entrega la información dentro del plazo establecido por esta Resolución, la persona reclamante puede ponerlo en conocimiento de la GAIP, preferentemente por correo electrónico dirigido a gaip@gencat.cat, a fin de que la Comisión requiera su cumplimiento. Mientras no se cumpla plenamente la Resolución, la Comisión difundirá en su web www.gaip.cat el incumplimiento de la Administración obligada, conforme al artículo 25.2.k RGAIP. Si la Administración no atiende el requerimiento de ejecución que le dirija la GAIP, la Comisión pondrá los hechos en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 LTAIPBG, y le solicitará la incoación de un procedimiento sancionador por infracción muy grave con relación al derecho de acceso a la información pública, al amparo del artículo 77.2.b LTAIPBG.

Todo ello sin perjuicio que la persona reclamante pueda, considerando que esta Resolución es un acto administrativo declarativo de derechos que vincula la Administración, requerir su ejecución ante los Tribunales, al amparo del artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esta acción se puede interponer después de que hayan transcurrido tres meses desde que la persona afectada ha reclamado formalmente y directamente a la Administración el cumplimiento de la Resolución.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un plazo de dos meses desde el día siguiente de la notificación de la Resolución, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.